

1500189-75.2022.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... além de praticar crime permanente, tráfico, resumido na manutenção da droga para o fim de traficar.

Mesmo que não houvesse sido pilhado vendendo a droga, a denúncia é certa em acusa-lo de guardar e ocultar drogas, para tráfico, a par de trazer uma pequena quantidade para o mesmo fim, tráfico imediações do bar.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500189-75.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500189-75.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2032325/2022 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA, 22816234 - 03º D.P. AMERICANA, 236/22/346 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA, 2032325 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIZEU GALEGO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

ELIZEU GALEGO está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, acusado de em 03 de fevereiro de 2022, por volta das 18h50, na Rua Mário de Andrade, 290, bairro Antônio Zanaga II, nesta cidade, guardar e ocultar, com a finalidade de tráfico, 1 (uma) pedra da droga conhecida como crack, forma sólida da droga cocaína, pesando cerca de 35g (trinta e cinco gramas); 73 (setenta e três) papелotes contendo a droga cocaína em pó, pesando cerca de 40g (quarenta gramas); 16 (dezesesseis) tijolos da droga conhecida como maconha

(tetrahydrocannabinol), pesando cerca de 9.910g (nove mil, novecentas e dez gramas), além de R\$ 5.030,00 (cinco mil e trinta reais) em dinheiro, substâncias estas causadoras de dependência química, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi instruída com Inquérito Policial. Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa e acusação. A denúncia foi recebida em 11 de abril de 2022 (fls. 215/216). Na instrução foram inquiridas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu. Sem mais requerimentos, nos debates, a acusação requereu a procedência da denúncia, alegando provados os fatos criminosos, em concurso material; materialidade e autoria das infrações. Discorre sobre pena e regime. A Defesa, em memoriais, invoca nulidade por invasão desautorizada de domicílio. Usurpação de função, pela guarda municipal. As provas seriam insuficientes. Não foi encontrado nada de ilícito com o acusado. Requer consideração de que o réu não era reincidente, tem residência fixa no distrito de culpa e a confissão espontânea de fatos que nem mesmo os policiais tinham conhecimento. Para o caso de condenação, pena mínima, com redução legal, regime brando. Requer, enfim, gratuidade processual (fls. 260/271). É o relatório.

DECIDO.

A preliminar não procede.

Pelo que se depreende dos autos, não houve abordagem ocasional e infundada, mas após a guarda receber informações sobre tráfico de drogas no local, inclusive com envio de imagens. Identificou o suspeito, praticando a venda de drogas para a testemunha José (fls. 08). Com o acusado, havia dinheiro e um celular. Ao se deslocarem até a casa do réu, o ingresso no imóvel foi autorizado expressamente por Jair e Roseli, que anuíram e assinaram o termo de consentimento para os guardas municipais (fls. 03/06), quando drogas e vultosa quantia foram encontradas, na forma descrita na denúncia.

A sua detenção ocorreu na via pública, não se cogitando por evidente de qualquer mandado judicial.

As diligências encetadas também recomendavam a busca excepcional no domicílio, tratando-se de crime permanente.

Enfim, havia indicativo de ocorrência de crime, que é permanente (tráfico) e a inviolabilidade do domicílio, para a realização da prisão em flagrante (não para a busca, como é a hipótese) assim, sofre atenuação pelo interesse coletivo em se apurar, prevenir e punir a prática de crime.

A ida à casa do réu, pois, não foi inventiva ou desproporcional, mas movida por denúncia e policiamento preventivo, com o réu negociando drogas, situação de crime. Vale dizer, necessário um controle judicial posterior da diligência, a fim de se definir se a ação era justificada.

Nesse desiderato, os policiais devem, em momento ulterior à diligência, indicar as razões que os levaram ao ingresso na casa.

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.

Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori.

Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de

proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (STF, RE nº 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes).

Em data recente, inclusive, também no Colendo Supremo Tribunal Federal:

“A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independente de mandado.” (RHC 213852 AgR, Relator (a) ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30 de maio de 2022, divulgado 31-05-2022, publ. 1º de junho de 2022).

E dantes, já proclamou o Supremo Tribunal Federal que “a casa é o asilo inviolável do indivíduo, porém não pode ser transformada em garantia de imunidade de crimes que em seu interior de pratiquem...”, de tal sorte que “em se tratando de flagrante delito, não é necessário mandado de busca e apreensão domiciliar...” (RE nº 86.926, rel. Min. Cordeiro Guerra).

No mérito, a denúncia é procedente.

Ao ser preso em flagrante, nada disse à autoridade policial, manifestando o desejo de permanecer calado (fls. 09).

“Na real verdade, preso naquelas circunstâncias a que a tradição do direito chama 'certeza visual do crime' (cf. Tostes Malta, do flagrante delito, 1933, p. 25), e permanecendo calado na Polícia (fl.7), em vez de repelir, com a última força, a imputação, como fazem os inocentes, apenas o decreto condenatório poderia atender a um tempo à prova dos autos, à razão lógica e aos ditames da Justiça. Cai a lança aquilo de Peter Thorton: 'A inocência pelo direito de falar; a culpa, essa invoca o privilégio do silêncio' (Justice on trial, p. 36; Revista da Escola Paulista da Magistratura, 2, p. 117). Impossível dizer melhor!” (TACRIM SP, 15ª C. – AP 1.286.483/3 – Rel. Carlos Biasotti, j. 07.02.2002, rolo-flash 1472/110).

“Embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência não se reservar para prestar esclarecimentos apenas em Juízo.” (Ap. Crim. 1070141/5, Taubaté, Rel. Renato Nalini, TACRIM SP, j. em 20.10.1997).

“PROVA. Interrogatório policial. Silêncio do réu. Valor. O silêncio do réu, quando interrogado na fase policial, direito constitucional que lhe foi assegurado é comprometedor, pois o inocente brada desde logo sua inocência e apresenta eventual alibi ou justificativa de seu ato.” (TACRIM SP, AC 1.288.149/1, SP, 8ª Câmara, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 13.12.2001).

No interrogatório judicial, alegou que era usuário de drogas. Já respondeu a processos por tráfico, mas ficou muitos anos “limpo”. Teve uma recaída no final do ano, voltou a fumar crack. Foi até a avenida, pegou um kit de 14 pedras, ganharia quatro pedras para fumar. Estava na Avenida, quando os guardas municipais chegaram. Naquele momento, tinha 5 pedras nas mãos, colocou-as em sua boca e as engoliu. Tinha a quantia de R\$ 90,00 no bolso para pagar o kit. Venderia mais uma e pagaria o kit, quando foi abordado. Os guardas não acharam nada em seu poder, foi colocado dentro da viatura e ali permaneceu. Era por volta de 17 horas. Perguntou para os guardas o que estava acontecendo. Disseram que estava enrolado, que tinha muita

droga envolvida. Os guardas não o levaram até a sua casa, eles não foram à sua residência. A residência era numeral 290, mas os guardas informaram que era nº 390. O bar era situado no bairro Antônio Zanaga. Estava no imóvel somente o seu pai e o seu irmão no imóvel. Não tinha tudo aquilo, não sabia como apareceram as drogas apreendidas. Se tivesse tudo aquilo, não estaria na Avenida, na calçada do bar, vendendo um kit para fumar um. Não tinha R\$ 5.000,00 em dinheiro. Fumava e os guardas disseram que era traficante, os seus antecedentes o condenava. Somente foi apresentado na Delegacia por volta de 20 horas. Explicou na Delegacia que não possuía nada daquilo, mas eles só tiraram sarro. Não prestou depoimento na Delegacia, nem teve audiência de custódia. Ponderou que não estaria na calçada de um bar, "vendendo B.O.Zinho", em troca de 4 pedras para fumar se tivesse um monte das drogas que os guardas alegaram. Não sabia se os policiais foram em outra casa, se eram outras pessoas envolvidas, pois tinha mais umas 3 ou 4 pessoas no Boletim de ocorrência. Desconhecia o que aconteceu. Realmente estava na calçada do bar e pegou um kit pra vender. Ficou muito tempo 'limpo', há muitos anos não tinha problemas com a Justiça. Após a recaída, no final do ano, voltou a fumar. Pegou um kit de drogas para vender, ganharia quatro para fumar.

Nada foi localizado em seu poder, engoliu cinco "B.Os", (cinco pedras). Não tinha tudo aquilo, os guardas não foram até a sua casa, nem o pegaram vendendo drogas por R\$ 20,00 para outra pessoa. "Foi abordado sozinho, no 'Favaro Bar", do Belmiro. Em seguida, os guardas foram em outro bar, onde outras pessoas foram enquadradas. Faltava vender mais uma para pagar o kit, que custava R\$ 100,00. Estava com R\$ 90,00, já tinha vendido nove do kit que pegou. Morava na Rua Mário de Andrade, 290. Morava com os seus pais e com o seu irmão. Os guardas não o levaram na casa, nem foram até a sua residência. Quando a sua família soube que a viatura o abordou na avenida, eles foram até a Delegacia para tentar o ajudar. Sua família chegou antes que ele chegasse com a viatura.

A versão não convence.

O guarda municipal Ivan Beraldo se lembrou de que receberam denúncia no WhatsApp da guarda municipal de Americana, dando conta do possível tráfico de drogas no Bar, situado na Avenida Cecília Meirelles. Pelas imagens, já conhecia o local, porém desconhecia o suspeito. Com base nas informações, deslocaram-se até o endereço, em posse das imagens. No momento da abordagem, observaram que havia um rapaz com o acusado. Foi possível observar que Elizeu passou algo para esse segundo envolvido. Abordou o rapaz que estava fora do bar, enquanto o colega de farda abordou ao réu. Com o rapaz que estava fora do estabelecimento, encontraram duas pedras de crack. Indagado, ele falou que era usuário de drogas, que tinha acabado de comprar as drogas do acusado, pela quantia de R\$ 20,00. Inclusive, a nota de R\$ 20,00 estava nas mãos do Elizeu. No momento em que averiguavam o estabelecimento para ver se tinha mais drogas, perceberam que o réu gesticulava para quem estava próximo do local da abordagem, o que gerou desconfiança de que ele sinalizava para desfazerem de possíveis entorpecentes que estivessem em sua casa. Assim, decidiram ir até a casa dele rapidamente, para verificar se havia mais drogas no imóvel. No local, fizeram contato com o pai de Elizeu, que permitiu que entrassem somente no quarto do acusado, tendo autorizado o ingresso mediante assinatura do BO/GM. No referido dormitório, localizaram em uma escrivaninha, uma pequena mesa no quarto de Elizeu, crack e cocaína, além de R\$ 5.000,00 e poucos reais em dinheiro.

Em uma bolsa, no chão, encontraram alguns tijolos de maconha, totalizando aproximadamente 10 quilos ou 9 quilos e pouco de entorpecentes.

Anderson Luiz de Andrade, outro guarda municipal, ratificando a versão do colega, relatou que chegou denúncia, via WhatsApp da Guarda Municipal de Americana, com imagens de um suspeito, que estava em um local já conhecido pela prática de tráfico de drogas, 'Fávaros Bar'. Havia imagens de Elizeu, que conversava com algumas pessoas que passavam por ali. Durante as conversas, ele recebia algo e também entregava algo em troca, passavam algo entre si, fato gravado em vídeo e enviado para a Guarda Municipal, por três vezes. Juntaram as equipes e foram até o endereço mencionado para averiguarem as informações. Ao se aproximarem do local, verificaram que Eliseu e outro envolvido passavam algo entre eles. Ambos tentaram deixar o local. Elizeu se abrigou no interior do estabelecimento, enquanto a outra parte

tentou se evadir, pela via pública. Realizou a abordagem de Elizeu no interior do estabelecimento comercial. Localizou nas mãos de Elizeu a quantia de R\$ 20,00, em cédula única, bem como em seu bolso encontraram mais a quantia de R\$ 350,00, em notas de R\$ 50,00 e R\$ 100,00, além de um aparelho celular. Com o outro envolvido, encontraram duas pedras de crack e uma quantia em dinheiro. Indagado, o outro suspeito informou que tinha comprado a droga de Eliseu há poucos momentos, que pagou com uma única cédula de R\$ 20,00. Eliseu negou que estivesse traficando. Questionaram se Elizeu guardava entorpecentes em sua residência, o que também foi negado. Em vários momentos, o acusado tentava enviar sinais para o público que estava nas proximidades, o que gerou desconfiança na equipe de que ele estivesse guardando alguma coisa em sua residência. Deslocaram até a residência informada pelo próprio Eliseu, fizeram contato com o pai e com a madrasta do acusado, que autorizaram a entrada na residência para averiguação, após serem cientificados sobre a denúncia que recaía sobre o acusado. No quarto de Eliseu, na gaveta da cômoda, o subinspetor Beraldo encontrou certa quantia de cocaína, crack e o dinheiro. Na sequência, encontraram uma bolsa no chão, ao lado da cama, que continha 16 tijolos de maconha. O pai e a madrasta do acusado acompanharam as buscas e viram quando encontraram os objetos. Os fatos foram apresentados na Central de Polícia Judiciária.

O local era conhecido como ponto de tráfico, porém, não conhecia o acusado. Pegaram autorização do pai e da madrasta de Elizeu por escrito para ingresso no imóvel, que ficou consignado no BO/GM nº 986, de 03 de fevereiro de 2022 e apresentado para a autoridade policial. O documento não ficou retido.

A testemunha José dos Reis Silva, ouvido apenas na fase policial, assegurou que realmente trazia com ele 02 (duas) pedras de Crack, que havia acabado de comprar para seu consumo, próximo ao 'Lázarus Bar'. Pagou a quantia de R\$ 20,00 em tal aquisição, tendo usado, para tanto, quatro notas de cinco reais. É ajudante de pedreiro e também vendia recicláveis, inclusive obtidos nas obras para o qual trabalha. Foi da venda de uma tubulação de cobre que conseguiu R\$ 70,00 e gastou R\$ 20,00, pela compra da droga, além de um isqueiro e um maço de cigarros que comprou naquele bar. Assim, restou a quantia de R\$ 39,50. Foi abordado por Guardas Municipais, que localizaram as duas pedras e com o troco que restara. Negou ter falado para os guardas municipais que comprou as drogas de Elizeu Galego. Não comprou drogas do acusado, mas de outro rapaz, que se encontrava naquele entorno, que não sabia identificar. Era usuário de crack, desde os 15 anos de idade, ficou um período sem usar. Recaiu no vício há um ano (fls. 08).

A prova é suficiente para a condenação do réu.

Antes de sua prisão, a descarada venda de drogas recomendou que populares o filmassem em plena ação criminosa, avisando aos Guardas Civis Municipais a respeito de suas características e locais em que ousava traficar.

Assim alertados, os Guardas Civis foram ao ponto de tráfico e chegaram a visualizar atitude nítida de tráfico, entre o réu e a testemunha já mencionada, com troca nítida de droga e numerário.

Abordado, o réu tinha mesmo dinheiro e drogas; o outro suspeito, drogas, além de resto de dinheiro, confessando que foi ao local para adquirir entorpecentes. Quis isentar ao réu, em vão, o que é habitual em circunstâncias parecidas.

Mais. O réu passou a gesticular, flagrado, para quem estivesse próximo de sua casa, evidenciando a intenção de se desfazer de drogas que lá estivessem, caso os Guardas Civis resolvessem ir ao endereço. E foi o que ocorreu, especialmente pela fundada suspeita advinda tanto do tráfico, quanto de seu comportamento.

Na casa, autorizados por parentes do réu, para busca exclusiva no quarto, os guardas apreenderam drogas variadas, com especial enfoque para a maconha, que pesava aproximadamente dez quilos e estavam em dezesseis tijolos. Também numerário de valor alto e não justificado pelo réu, mais de cinco mil reais.

As circunstâncias da prisão em local já conhecido como ponto de tráfico; a apreensão das drogas, já embaladas em pequenas porções, prontas para a venda e entrega ao consumo de terceiros; tentativa de fuga do acusado, que foi imediatamente perseguido e detido pelos guardas municipais, evidencia que ele vinha se dedicando a essa atividade criminosa.

Em suma, a prova não autoriza qualquer hesitação quanto ao convencimento da responsabilidade criminal do réu, mercê das condutas já delineadas, que guardava e ocultava entorpecentes, além de praticar crime permanente, tráfico, resumido na manutenção da droga para o fim de traficar.

Mesmo que não houvesse sido pilhado vendendo a droga, a denúncia é certa em acusá-lo de guardar e ocultar drogas, para tráfico, a par de trazer uma pequena quantidade para o mesmo fim, tráfico imediações do bar.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

A quantidade da droga, embalada em porções, sua variedade, é típica de tráfico. Indiferente à alegação do réu, assim, de que não teria envolvimento com o tráfico, na conduta de vender o entorpecente, ainda que desmentida pelos guardas civis, na medida em que a acusação é certa de imputar a ele também a conduta de guardar e ocultar, para esse fim.

A versão de Guarda Municipal, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros

elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Finalmente, no C. STJ:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Em suma, a prova não autoriza qualquer hesitação quanto ao convencimento da responsabilidade criminal do réu, mercê das condutas já delineadas, que ocultava drogas, em quantidade expressiva, além de guardar na casa, com livre disposição e acesso.

O fato de ser usuário de drogas não afasta a traficância, quando o porte de eventual droga é absorvido pelo crime de maior severidade, no caso, o tráfico.

A alegação de necessidade, em sua versão, de todo o modo não lhe dá direito ou permissão para guardar e ocultar drogas, para o grave crime de tráfico.

Incabível o reconhecimento de inexigibilidade de conduta porque não comprovado que o meio escolhido era o único disponível diante da situação.

Nesse sentido:

Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Acusação pugna pelo afastamento da redutora do §4 do art. 33. Privilégio mantido, com fração reduzida. Réu primário e portador de bons antecedentes. Regime inicial alterado para o semiaberto. Grande quantidade e variedade de drogas. Tese de inexigibilidade de conduta diversa não acolhida. Não comprovação de que, de fato, o meio escolhido era o único disponível diante da situação. Confissão que já foi reconhecida, mas sem reflexo na pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não permitida. Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso defensivo não provido (TJSP; Apelação Criminal 1503966-14.2018.8.26.0050, 7ª Câmara de Direito Criminal; J. em 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020).

A prova, enfim, é boa e suficiente, com prisão em flagrante delito, certeza visual do delito, apreensão da droga e depoimentos de policiais.

O réu, também, não era iniciante na prática de crimes, bem demonstrando que o cometimento de ilícitos não eram novidades em seu passado inglório.

A materialidade da infração, no tráfico, foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16 e 50), pelo laudo de constatação (fls. 19/21 e 51/52), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 110/112), bem como pelo laudo pericial de conversão de vídeo em fotos (fls. 156/205).

Daí porque de rigor a condenação.

Fixação das penas.

Na primeira fase, observo que o réu registra condenações. Apenas uma condenação será considerada para reincidência (Processo nº 0014969-32.2001.8.26.0019 - 2ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, incurso no Art. 12, da Lei nº 6.368/76; com trânsito em julgado para a Defesa em 04/10/2005). A outra, embora apta para o mesmo fim, para evitar 'bis in idem' será considerada como circunstância judicial, evidenciando os seus maus antecedentes, de há muito.

Assim já se pacificou que a reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, desde que fundadas em condenações distintas e transitadas em julgado.

"O uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, nem viola a Súmula 241/STJ.". (TJDF APR 10250110093863; no mesmo sentido, STJ, HC 306.222/RS).

"(...) o juiz, ao aplicar a agravante da reincidência, necessita verificar, com atenção, qual é o antecedente criminal que está levando em consideração para tanto, a fim de não se valer do mesmo como circunstância judicial, prevista no art. 59 (maus antecedentes). Nessa ótica: Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça: 'A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial'. Note-se, entretanto, que o réu possuidor de mais de um antecedente criminal pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de mau antecedente (...)" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos

Tribunais, 2013. p. 465-466).

Aumento a pena base em um sexto, pelos maus antecedentes.

Na segunda, pela reincidência específica (Processo nº 0012567-36.2005.8.26.0019 - 1ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, incurso no Art. 12, da Lei nº 6.368/76; com trânsito em julgado para a Defesa em 12/02/2008). Embora o réu tenha feito confusa confissão dos fatos, ou seja, de que traficava em troca de droga para consumo, não é possível considerar tal circunstância atenuante.

É que, além de não ter confessado integralmente, negou a venda para o terceiro, ali presente, também negou a propriedade das demais drogas e valores apreendidos em sua casa. É igualmente multirreincidente. Exaspero a pena em mais um sexto.

Em terceira e última fase, impossível redução da pena, com base no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, porque reincidente. E a pena final, por si, impõe óbice a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis.

O réu deverá cumprir pena no regime inicial fechado, pela mesma reincidência.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu para condenar ELIZEU GALEGO, às penas de seis (06) anos, nove (09) meses e vinte (20) dias de reclusão, regime inicial fechado e seiscentos e oitenta (680) dias-multa, piso, por infração ao artigo 33, 'caput', da Lei 11.343/2006, c.c. artigo 61, I, do Código Penal.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Isento o réu de custas, assistido que está por defensora nomeada e presumida a necessidade (fls. 152).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Vinculado o numerário apreendido com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, bem como os objetos apreendidos, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Preso preventivamente e tendo respondido a todos os atos do processo recluso, deve assim permanecer, para garantir a eficaz aplicação da lei penal, a par de manutenção da ordem pública, rotineiramente abalada por crimes de gravidade e hediondo, como o tráfico. Interessa as suas prisões para a eficaz aplicação da lei penal.

(- HABEAS CORPUS ". ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. Réu que permaneceu no cárcere durante toda a marcha processual. Condenação. Manutenção na prisão em virtude da sentença condenatória. Entendimento pretoriano prevalente. Legalidade. Ordem denegada. (TJ-MG; HC 1.0000.05.426655-6/000; Juiz de Fora; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro; Julg. 27/10/2005; DJMG 24/11/2005).

"Não fere o princípio da presunção de inocência a determinação de que o sentenciado se recolha à prisão para aguardar o julgamento de recursos que, em regra, são desprovidos de efeito suspensivo" (STJ, HC 10.313 SP 5ª T., Rel. Edson Vidigal, 09.11.1999, vu DJ 13.12.1999, p. 165).

Recomendem-se o réu.

P.I.C.

Americana, 03 de junho de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA